

1500138-90.2021.8.26.0539

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo

Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... pela sua reiterada conduta criminosa relacionada ao tráfico de drogas, sendo o réu conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas há algum tempo e pelas denúncias anônimas que vinham ocorrendo, também pelo conhecimento do local pelos policiais e testemunhas como ponto de tráfico de drogas muito conhecido na cidade, demonstrando que a conduta criminosa em tela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara Criminal

Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, Nº 606, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - cep 18900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500138-90.2021.8.26.0539 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500138-90.2021.8.26.0539

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2033805/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 16062670 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

230/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2033805 - DEL.POL.ESPIRITO S. DO TURVO,

230/21/505 - DEL.POL.ESPIRITO S. DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO RODRIGUÊS DA CRÚZ e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou RICARDO RODRIGUÊS DA CRÚZ, RG nº 49678993-SP, vulgo: "Nenê", com 28 anos na data dos fatos e IVAN ROBERTO SAMPAIO, RG nº 52241923-SP, vulgo "Pelezinho", com 18 anos, já qualificado nos autos, dando-os como incurso na conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 ("Lei de Drogas") c.c artigo 29, caput, do Código Penal.

Segundo a narrativa exordial, no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta de 20h30min, na residência localizada na Rua João Eugênio, nº 102, Jardim Vitória, na cidade de Espírito Santo do Turvo, nesta Comarca, o réu Ivan previamente acordado e em unicidade de propósitos com Ricardo, trazia consigo para fins de venda, entrega

ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, substância entorpecente, consistente em 101 (cento e quatro) porções de crack, individualmente embaladas em plástico e ligadas umas às outras em forma de tiras, com massa líquida de 7,38g. Também mantinham em depósito, para idênticos fins, mais 60 (sessenta) porções de cocaína, individualmente embaladas em microtubos plásticos, conhecidos como eppendorfs, com massa líquida de 8,9g; 01 (uma) porção à granel de cocaína, com massa líquida de 47,12g; 01 (um) tablete de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 322,21g; e, por fim, 02 (duas) porções da mesma droga, individualmente embaladas em plástico, com massa líquida de 1,58g, substâncias entorpecentes que causam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2021 (fls. 131).

Devidamente citados (fls. 162 e 165), os réus apresentaram resposta escrita à acusação às fls. 171/173 e 180/181, pugnando pela absolvição sumária.

Foi negada a absolvição sumária dos réus pela decisão de fls. 182/184, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 25 de junho de 2021.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, interrogados os réus.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados, sustentando que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para embasar um decreto condenatório.

A defesa, por sua vez, postulou a absolvição dos réus.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

1. Análise preliminar.

Por proêmio, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais que norteiam o processo penal, na medida em que as provas colhidas durante a fase extrajudicial são legítimas e estão respaldadas por elementos probatórios. Não se olvide que se trata de fase não sujeita ao contraditório, sendo certo, ainda, que mera irregularidade que eventualmente nela se observasse não necessariamente contaminaria o processo judicial.

Verifico, ainda, que os réus foram devidamente representados por defesa técnica em todos os atos do processo, não se verificando irregularidade procedimental ou demonstração concreta de prejuízo.

Dessa maneira, o feito se encontra em termos para o enfrentamento do mérito.

2. Das provas produzidas.

Cuida-se de ação penal promovida pela Justiça Pública contra os réus, imputando-lhes a prática do crime de tráfico de drogas, praticado nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na peça exordial.

Da documentação juntada aos autos, reputo relevante o auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), o boletim de ocorrência (fls. 10/14), o auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), o laudo de constatação provisória (fls. 25/28) e o laudo toxicológico definitivo (fls. 112/115) e laudo dos objetos apreendidos (fls. 193/198).

A testemunha SAMUEL MARTINS DE SOUSA, prestou declarações na fase inquisitiva (fls. 5), dizendo que foi comprar drogas na "biqueira", onde é a casa de "Pelezinho", comprou uma porção de maconha por dez reais de "Pelezinho", momento em que a polícia chegou e ambos saíram correndo. Foi a primeira vez que comprou maconha no local e não sabe se há venda de outras espécies de droga. Em Juízo, SAMUEL disse que na data dos fatos, estava no local para conversar com Ivan para saber de uma casa para alugar. Ricardo não estava no local e não o viu em nenhum momento. Os policiais militares chegaram e invadiram a casa e o abordaram. Não sabe se os policiais encontraram drogas na casa. Havia indicado Ivan porque algum familiar dele tinha casa para alugar. Não soube dizer o nome do parente que tinha casa para alugar. Somente viu as drogas quando estava na delegacia. Questionado pelo motivo de ter corrido quando chegou os policiais, disse que correu por medo, mas não sabia o que estava acontecendo. Questionou por que estava sendo levado pela polícia e eles disseram que era por tráfico. Não conhecia Ivan e nem seu apelido. Estava trabalhando na cidade quando os fatos aconteceram, pois morou algum tempo na cidade. Não faz uso de nenhuma droga.

THIAGO LUIZ CIRELLI, policial militar, em Juízo, informou que é da força tática de ourinhos e na data dos fatos, se dirigiu à Cidade de Espírito Santo do Turvo/SP, junto à força tática, para apurar denúncias de tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo, por alguns indivíduos que residiam em uma residência. Visualizou em frente ao imóvel um indivíduo que inicialmente não notou sua presença, mas quando se aproximou, ele tentou fugir, entrando no imóvel. Posteriormente o indivíduo foi qualificado como Samuel e com ele havia uma porção de maconha. Adentraram a residência e encontraram Ricardo e Ivan sentados em uma mesa com mais duas porções de maconha e fugiram. Ivan tentou fugir com Samuel pelo telhado das residências vizinhas e Ricardo tentou se trancar no banheiro, nada com ele foi encontrado. Samuel foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele. Perderam Ivan de vista por um breve momento, mas foi encontrado posteriormente porque havia caído do telhado e estava sob o chão de uma cozinha. Com ele foram encontrados cento e uma pedras de crack e o valor de trezentos e noventa e seis reais. Retornaram ao imóvel e durante buscas e onde ficava Ricardo encontraram sob um sofá, uma balança de precisão, um tijolo de maconha, diversas embalagens, uma faca com resquícios da mesma droga. No quarto de Ivan foram localizados 60 eppendorfs de cocaína e uma porção bruta da mesma droga, além das duas porções de maconha encontradas na mesa anteriormente. Conversou com Samuel e ele alegou ser usuário de maconha e havia ido comprar drogas de Ivan e Ricardo naquele local, por se tratar de uma "biqueira" onde tinha conhecimento que muitas pessoas iam comprar a droga, reforçando as denúncias anônimas que receberam. Ivan e Ricardo eram muito conhecidos nos meios policiais como traficantes de drogas, por isso, os policiais da cidade já conheciam até o local das denúncias anônimas e direcionaram ele até a residência no dia dos fatos. As denúncias ocorriam há meses sobre Ricardo, segundo os policiais da cidade. Não tinham autorização para entrar na casa.

MURILO COLOMBO NANTES, policial militar, em Juízo, corroborou com o depoimento de seu colega de farda.

DONILVADO GARCIA TAIQUI, em Juízo, informou que é integrante da força tática e recebeu informações de batalhões da cidade de Espírito Santo do Turvo, sobre denúncias de tráfico de drogas na cidade. Sobre Ivan e Ricardo, as denúncias vinham ocorrendo há três meses e diziam que eles eram os principais responsáveis pelo tráfico de drogas na cidade. Na data dos fatos, se deslocaram até a cidade afim de realizar abordagens e prisões. Pediram informações sobre a localização dos indivíduos da denúncias e foram até a residência apontada. Chegando ao local, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Samuel, tentaram a abordagem, mas ele empreendeu fuga. Na residência havia mais dois indivíduos, sentados em uma mesa, manuseando drogas e embalagens. Ao verem Samuel correndo, também correram, sendo que Ivan correu para os fundos do quintal com Samuel e pularam o muro, adentrando nas residências vizinhas. Ricardo entrou e se trancou no banheiro, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Ficou supervisionando Ricardo enquanto seus colegas iam atrás de Ivan e Samuel. Seus colegas retornaram com os dois e Samuel disse que era usuário de drogas e estava ali para comprar maconha e que o local era a "biqueira" mais conhecida da cidade e que várias vezes havia adquirido drogas ali. Ivan havia caído do telhado de uma residência e caído dentro dela, os vizinhos haviam acionado a polícia e os policiais conseguiram capturar Ivan. Após abordagem de Ivan, encontrou 101 pedras de crack e trezentos e noventa e seis reais. Foi acionado o Samu porque Ivan havia se machucado durante a queda. Fizeram busca na residência de Ivan e Ricardo, na residência de Ricardo, sob o sofá foi encontrada uma balança de precisão, um tablete de maconha, embalagens plásticas e uma faca com resquícios de maconha. Na residência de Ivan foram localizados 60 eppendorfs de cocaína e uma porção bruta da mesma droga. Sob a mesa da residência onde eles estavam inicialmente havia duas porções de maconha e embalagens plásticas.

Na fase policial (fls. 7), o réu IVAN ROBERTO SAMPAIO relatou que caiu do telhado e foi atendido na UPA desta cidade. Estava vindo de uma estrada de terra e os policiais o abordaram, mas não havia nenhuma droga com ele. A droga apreendida em sua residência não lhe pertencia. Em Juízo, IVAN disse que todas as drogas lhe pertenciam, estava vendendo drogas para pagar seu aluguel, estava desempregado,

estava vendendo as droga há um mês. A droga estava toda com ele em uma sacola. Samuel foi comprar drogas, mas só havia visto ele no local comprando drogas duas vezes. não vendeu muitas drogas no local, vendeu somente o necessário para pagar seu aluguel. Havia pagado quinhentos reais por toda a droga. Vendia maconha por vinte e a cocaína por dez reais. Não conhecia os policiais que o abordaram. Ricardo havia se mudado no dia 15. Nunca viu Ricardo usando drogas, não tinha contato com ele, ele não sabia que havia venda de drogas no local. Foi “desmaiado” pelos policiais. Ricardo veio de Iaras. Samuel e ele correram justos no momento da abordagem, mas foi pego pelos policiais e não deu tempo de pular o muro porque eles o agrediram e Ricardo estava no banheiro e não estava com ele.

Na fase policial (fls. 6), o réu RICARDO RODRIGUÊS DA CRÚZ relatou que estava tomando banho quando policiais militares chegaram em sua residência e nenhuma droga lhe pertence, mora na casa dos fundos e as drogas apreendidas estavam na casa em frente. Em Juízo, RICARDO disse que os policiais são mentirosos porque morava em outra residência do quintal, não tinha nada a ver com os fatos, estava tomando banho quando os policiais chegaram e não havia nenhuma droga em sua residência, somente havia na casa da frente, que era a casa de Ivan. Viu a droga que foi apreendida, eram 60 pedras de crack e duas porções de maconha. não estava na mesa na residência de Ivan no momento da abordagem. Não conhece os policiais, mas são mentirosos, porque não havia denúncias sobre ele, porque havia poucos dias que morava no local. Não conhecia Samuel. Mudou-se dia 15 de janeiro para a casa citada, fazia “bicos” para complementar sua renda. Antes morava em Iaras. Os policiais chegaram por volta das 8h da manhã. Antes da sua prisão, era usuário de drogas.

3. Da valoração das provas produzidas.

As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto a materialidade do crime e sua autoria, sendo certo que a dinâmica delitiva ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em data, hora e local já mencionados, os réus Ivan e Ricardo, previamente acordados e em unicidade de propósitos, traziam consigo e mantinham em depósito para fins de venda, entrega ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, substância entorpecentes.

A materialidade resultou fartamente comprovada. Houve apreensão de 101 (cento e uma) porções de crack, pesando 7,38g; 60 (sessenta) porções de cocaína, pesando 8,9g; 1 (uma) porção à granel da mesma droga, pesando 47,12g; 1 (um) tablete de maconha, pesando 322,21g; além de, 2 (duas) porções da mesma droga, pesando 1,58g, cujas características foram devidamente confirmadas pelos laudos de exame químico-toxicológico de fls. 112/115.

A autoria também é certa.

Conforme se extrai das provas colhidas, os policiais militares da força tática de ourinhos/SP, em operação que visava combater o tráfico de drogas, foram acionados pelos policiais de Espírito Santo do Turvo/SP para apurar diversas denúncias que vinham recebendo há meses sobre um suposto ponto de tráfico de drogas, residência dos réus.

No local, avistaram um indivíduo em frente à residência, posteriormente identificado como Samuel, que foi seguido por eles. Também viram Ivan e Ricardo no local, que correram. Ricardo para o interior de um banheiro da casa, enquanto Ivan, que se juntou a Samuel, fugiu para os fundos da residência pulando muros e subindo nos telhados das casas vizinhas.

Ricardo foi abordado no interior do banheiro, nada sendo apreendido em seu poder. Samuel também foi abordado e disse estar ali para comprar drogas porque se tratava de uma “biqueira”. Comprou uma porção de maconha de Ivan, pelo valor de R\$ 10,00 usou no local. Informalmente aos policiais militares informou já ter comprado droga no local com os réus em outras oportunidades, versão que confirmou perante a Autoridade Policial, embora em juízo tenha modificado.

Ivan fugiu pulando muros e telhados, foi perseguido, mas perdido de vista, até que Moradores de uma residência próxima solicitaram a presença dos policiais no interior da moradia, pois ele havia caído na cozinha, após danificar o telhado. Com

Ivan foram apreendidas drogas e dinheiro, assim como também foram encontradas drogas em sua residência.

Nas dependências da casa de Ricardo, foram apreendidas drogas e apetrechos para realizar o tráfico.

Os réus negaram a realização do tráfico de entorpecentes, bem como a propriedade dos entorpecentes e objeto apreendidos perante a Autoridade Policial, porém, como visto, em Juízo, Ivan alterou a versão, assumindo a autoria delitiva exclusivamente para si.

Em que pese qualquer alegação por parte dos réus, a traficância conjunta pelos réus está demonstrada pela prova oral colhida, pela prisão em flagrante dos acusados, pela grande quantidade de entorpecentes que traziam consigo e mantinham em depósito, pela variedade, pela forma de acondicionamento das drogas, pela apreensão de material utilizado para individualizar o entorpecente, pela balança de precisão e faca apreendidas, assim como pelas circunstâncias da abordagem, que são detidamente relatadas pelos policiais militares e confirmam as denúncias anônimas recebidas, que davam conta da traficância por eles há pelo menos três meses.

A atuação dos agentes públicos revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Neste norte, "os depoimentos prestados pelos policiais militares, conforme a jurisprudência já pacificada, constituem meio idôneo à formação da convicção do magistrado, quando em conformidade com as demais provas dos autos. São, portanto, válidos e aptos, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa" (STJ. Garga no AREsp 262.655/SP. 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 e STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

O tráfico de entorpecentes é crime grave e de natureza hedionda, inserido, ainda, pelo legislador na Lei nº 8.072/90. O delito ocorre em veraz crescimento e que vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos.

É considerado crime de perigo abstrato, bastando que o agente pratique quaisquer das condutas previstas no tipo para configurar o delito, prescindindo, dessa forma, que o agente seja flagrado no ato de mercancia da droga propriamente dito ou que a conduta seja direcionada a uma pessoa específica.

O delito pode ser cometido pelo agente visando o lucro ou ser praticado "ainda que gratuitamente", desde que esteja praticando quaisquer das condutas "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", uma vez que, não estando preenchido este requisito, a conduta seria atípica. Assim, muito embora a expressão "tráfico de drogas" esteja relacionada ao conceito de mercancia e lucro, não há essa necessidade, bastando que o agente pratique qualquer uma das dezoito condutas descritas no artigo para sua tipificação.

A jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância.

Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP, Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

No mais, ainda que ficasse provada, a condição de usuário não exclui, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP, Apelação Criminal nº 1.167.864.3, rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara Criminal, j. 15.05.08).

Consoante ensina Guilherme de Souza Nucci, "para a correta tipificação da conduta, é fundamental que se verifiquem os elementos pertinentes à natureza da droga, sua

quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias que envolvem a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (Leis Penais e processuais penais comentadas - 2ª ed. - Ed. RT - pág. 307).

Registre-se, por outro lado, que a simples guarda das drogas, desde que não destinadas ao consumo pessoal, já configura o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, afigurando-se irrelevante perquirir se os réus já as tinham vendido ou iriam vendê-las.

Restou suficientemente comprovada a prática do tráfico de drogas, sendo de rigor a imposição da reprimenda legal prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 ("Lei de Drogas").

Nesse diapasão, as teses defensivas restam isoladas nos autos e só podem ser creditadas ao direito de ampla defesa.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime e inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos réus ou extingam a punibilidade, reconheço a responsabilidade penal dos réus.

Passo à análise das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal, com o objetivo de, ao individualizar a pena, eleger a justa e adequada sanção penal.

4. Da dosimetria da pena

Para o crime de tráfico de drogas, o art. 33 da Lei de Drogas prevê a pena de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

4.1. RICARDO RODRIGUÊS DA CRUZ

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi normal à espécie. Os réus não ostentam Maus Antecedentes (vide fls. 367/369). Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar a pena do réu. Os motivos são normais ao crime praticado, voltados para a obtenção de lucro fácil por meio da venda de substância ilícita. As circunstâncias são anormais à espécie, devendo ser considerado como circunstância negativa a realização do crime em concurso de agentes, circunstância que facilitou sobremaneira a realização da conduta criminosa perpetrada pelos acusados. A natureza e a quantidade das drogas merecem valoração negativa nesta fase.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena-base 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que não há agravantes ou atenuantes a serem valoradas, mantendo-se a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase estão ausentes quaisquer causas de aumento, não sendo o caso de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O mencionado dispositivo estabelece que "Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

A criação da minorante tem raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legal ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a permitir uma oportunidade de ressocialização mais eficaz, prevendo a possibilidade de diminuição da pena privativa de liberdade de um sexto a dois terços.

Contudo, mostra-se inaplicável a referida minorante à espécie pela ausência de preenchimento dos requisitos legais. O dispositivo afasta a possibilidade de aplicação diante da dedicação do réu a atividades criminosas, o que fica evidenciado pela sua reiterada conduta criminosa relacionada ao tráfico de drogas, sendo o réu conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas há algum tempo e pelas denúncias anônimas que vinham ocorrendo, também pelo conhecimento do local pelos policiais e testemunhas como ponto de tráfico de drogas muito conhecido na cidade, demonstrando que a conduta criminosa em tela não foi uma conduta criminosa isolada ou de um agente iniciante no tráfico de drogas, o que também fica evidenciado pela grande quantidade de drogas apreendidas com ele, o que

descaracterizaria a conduta de um pequeno traficante iniciante. Dessa forma, torno definitiva a pena até aqui aplicada.

Para fixação do regime inicial de cumprimento da pena para o réu, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90.

Nunca é demais lembrar que, por expressa disposição legal, ao fixar o regime prisional, deve o Juiz levar em conta as circunstâncias do crime e personalidade do agente, não sendo o regime inicial de cumprimento da pena, portanto, consequência automática do "quantum" fixado para o castigo reclamado pelo crime.

No caso sob análise, considerando o montante da reprimenda aplicada e as circunstâncias que envolvem o delito, fixo o regime fechado para cumprimento da pena, em observância aos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Com relação ao texto da Lei 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art. 112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ausente prova da condição financeira do réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

4.2. IVAN ROBERTO SAMPAIO

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi normal à espécie. O réu não ostenta Maus antecedentes (vide fls. 67). Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar a pena do réu. Os motivos são normais ao crime praticado, voltados para a obtenção de lucro fácil por meio da venda de substância ilícita. As circunstâncias são anormais à espécie, devendo ser considerado como circunstância negativa a realização da conduta em concurso de agentes, circunstância que facilitou sobremaneira a realização da conduta criminosa perpetrada pelos acusados. Por sua vez, as consequências são apenas aquelas inerentes ao delito. Não há comportamento da vítima a ser analisado. A natureza e a quantidade das drogas merecem valoração negativa nesta fase.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que não há agravantes a serem valoradas, porém, há presença da atenuante da confissão espontânea, que ocorreu na fase judicial. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE:

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A circunstância atenuante pertinente à confissão espontânea, ainda que parcial, é aplicável àquele que confessa a autoria do crime independentemente da admissão do dolo ou das demais circunstâncias narradas na denúncia. Precedentes. 2. Habeas corpus concedido (STF - HC: 99436 RS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-235 DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 06-12-2010 EMENT VOL-02445-01 PP-00113). Além dessa atenuante, o réu tinha 18 (dezoito) anos na época dos fatos, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa. À vista de duas atenuantes, de rigor a redução da pena em 1/3 (um terço), impondo-se à recondução da pena ao patamar mínimo legal, não abaixo deste em razão entendimento sumulado no verbete nº 231, do c. STJ, que assim dispõe: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase estão ausentes quaisquer causas de aumento, não sendo o caso de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O mencionado dispositivo estabelece que "Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

A criação da minorante tem raízes em questões de política criminal, surgindo como

um favor legal ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a permitir uma oportunidade de ressocialização mais eficaz, prevendo a possibilidade de diminuição da pena privativa de liberdade de um sexto a dois terços.

Contudo, mostra-se inaplicável a referida minorante à espécie pela ausência de preenchimento dos requisitos legais. O dispositivo afasta a possibilidade de aplicação diante da dedicação do réu a atividades criminosas, o que fica evidenciado pela sua reiterada conduta criminosa relacionada ao tráfico de drogas, sendo o réu conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas há algum tempo e pelas denúncias anônimas que vinham ocorrendo, também pelo conhecimento do local pelos policiais e testemunhas como ponto de tráfico de drogas muito conhecido na cidade, demonstrando que a conduta criminosa em tela não foi uma conduta criminosa isolada ou de um agente iniciante no tráfico de drogas, o que também fica evidenciado pela grande quantidade de drogas apreendidas com ele, o que descaracterizaria a conduta de um pequeno traficante iniciante. Dessa forma, torno definitiva a pena até aqui aplicada.

Para fixação do regime inicial de cumprimento da pena para os réus, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90.

Nunca é demais lembrar que, por expressa disposição legal, ao fixar o regime prisional, deve o Juiz levar em conta as circunstâncias do crime e personalidade do agente, não sendo o regime inicial de cumprimento da pena, portanto, consequência automática do “quantum” fixado para o castigo reclamado pelo crime.

No caso sob análise, considerando o montante da reprimenda aplicada e as circunstâncias que envolvem o delito, fixo o regime fechado para cumprimento da pena, em observância aos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Com relação ao texto da Lei 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art. 112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ausente prova da condição financeira do réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

5. Dispositivo.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar RICARDO RODRIGUES DA CRUZ ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, arbitrados no mínimo legal, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. art. 29, caput, do Código Penal; e IVAN ROBERTO SAMPAIO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrados no mínimo legal, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. art. 29, caput, e 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em razão da natureza do delito e do quantum da pena fixada, nos termos do artigo 44, I e 77, caput, do CP.

Os réus não têm o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, “a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal” (STJ, HC nº 62.175 – SP, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 02.10.2008, DJe 28.10.2008). No mais, as circunstâncias do caso concreto, demonstram a periculosidade dos agentes, justificando-se a prisão para o resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante da probabilidade de fuga, considerando a pena e o regime a que foi condenado.

Recomendo os réus na prisão em que se encontram.

Tratando-se de réus preso pelo processo, havendo interposição de recurso pelas

partes, expeça-se guia de execução provisória, remetendo-a à Vara de Execuções competente.

Decreto a perda dos objetos apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas, exceto do celular. Trata-se dos meios utilizados pelo agente para cometer o tráfico. Quanto ao celular, entendo ausente elementos que demonstrem nos autos a utilização dos aparelhos para o tráfico, Assim, o aparelho telefônico deve ser restituído ao proprietário, que poderá fazer a retirada até 10 (dez) após o trânsito em julgado, sob pena de perdimento automático e destruição.

Decreto a perda em favor da União do dinheiro apreendido.

Fixo os honorários do Defensor dativo no máximo da tabela.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado desta sentença: a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG; b. intimem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias; c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal; d. elabore-se cálculo da pena de multa, intimando-se as partes para manifestação; e. Encaminhe-se ao SENAD relação dos bens declarados perdidos para os fins de sua destinação, à guisa do constante no art. 63, §4º, da Lei n. 11.343/06; e. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

P.I.

Santa Cruz do Rio Pardo, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA